主題：代理

壹、體系圖

<table>
<tr><td rowspan="7">直接代理</td><td rowspan="4">意定代理</td><td rowspan="2">有權代理</td><td colspan="2">顯名代理</td></tr>
<tr><td colspan="2">隱名代理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">廣義無權代理</td><td colspan="2">狹義無權代理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">廣義表見代理</td><td>狹義表見代理</td></tr>
<tr><td>越權代理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代理</td><td colspan="3">有權代理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">無權代理</td><td colspan="2">狹義無權代理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">廣義表見代理？</td><td>狹義表見代理</td></tr>
<tr><td>越權代理</td></tr>
<tr><td colspan="4">間接代理（並非代理）</td></tr>
<tr><td colspan="4">代表（視為本人之行為）</td></tr>
</table>

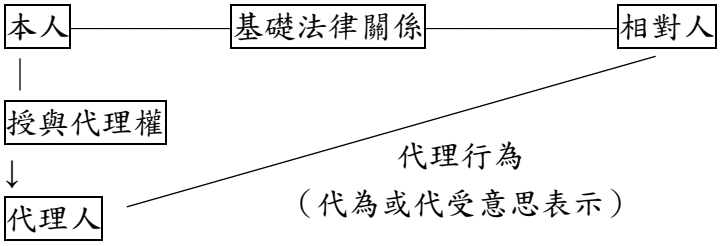
貳、概論

民法第 103 條

I. **代理人**於**代理權限內**，以**本人名義**所為之**意思表示**，**直接對本人發生效力**。

II. 前項規定，於應向本人為意思表示，而向其代理人為之者，準用之。

所謂代理，指**代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，或代理本人受意思表示，而意思表示直接對本人發生效力的行為**[1]。當事人法律關係，可以分成三個主體：本人、代理人、相對人。



[1] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 416，2022 年。

一、意定代理與法定代理

而代理，可以區分為**意定代理**和**法定代理**，前者，**代理權的來源乃是本人的代理權授與行為**；後者，**代理權的來源乃是法律規定**，例如：民法第 1086 條第 1 項父母為子女的法定代理人。而代理權的授與行為，依照民法第 167 條為之。

而區分意定代理和法定代理的實益在於：是否有**狹義表見代理之適用**（民法第 169 條）？實務見解認為，法定代理並無有狹義表見代理之適用[2]，而學者認為其理由在於：1.民法第 169 條有「**由自己之行為表示以代理權授與他人**」的**文義限制**，法定代理並非基於代理權授與 2.**法定代理有其既有既定範疇**，難以想像有表見代理之適用[3]。

二、有權代理與無權代理

意定代理，又依照代理權限之有無，區分為有權代理跟無權代理，而有權代理，乃是代理行為最理想的狀態，因此法律效力可以直接在本人和相對人之間發生效力，而無權代理，又可以根據交易安全是否需要保障，區分為狹義無權代理和廣義表見代理，前者，須本人承認後法律效力才會對本人生效，否則處於效力未定之狀態；後者，雖然代理人並無代理權（或逾越權限），但基於交易安全的保護，仍使法律行為效力發生在本人身上。

三、直接代理與間接代理

另外，所謂的直接代理，指代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，或代理本人受意思表示，而意思表示直接對本人發生效力的行為。**間接代理，指代理人以自己名義為本人之計算而為法律行為**[4]，區分的重點在於**到底是以誰的名義作成該法律行為**。

而一個極為重要的概念是：**間接代理並非代理**[5]，**因為本人與相對人之間並無任何法律關係存在，而無法直接向相對人請求**[6]，茲以圖示如

---

[2] 「**民法第一百六十九條關於表見代理之規定，惟意定代理始有適用，若代表或法定代理則無適用該規定餘地**。」最高法院 79 年度台上字第 2012 號民事判決、最高法院 74 年度台上字第 2014 號民事判決參照。至於越權代理（民法第 107 條），實務尚未表示意見，學說上肯否兩說均有，洪遜欣老師認為，**法定代理就其代理權限有限制，仍有適用越權代理之可能**；陳聰富老師認為，**基於保護未成年人之理由，不應該適用越權代理使未成年人負擔過重責任**，參陳聰富，註 1，頁 456、457。

[3] 曾宛如，公司內部意思形成之欠缺或瑕疵對公司外部行為效力之影響：兼論董事（長）與經理人之代表權與代理權，臺大法學論叢，47 卷 2 期，頁 733，2018 年。

[4] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 563，2024 年。

[5] 王澤鑑，註 4，頁 564；陳聰富，註 1，頁 425。

[6] 「受任人本於委任人所授與之代理權而以自己之名義與他人為法律行為，對委任人不生效力。**其委任人與法律行為之他造當事人間並不發生何等法律關係，僅該受任人負有將其法律效**

下：

本人－基礎法律關係－－間接代理人－－基礎法律關係－相對人

案例：甲請同事乙替自己叫外送當午餐，乙遂以自己的姓名和手機號碼向餐廳丙訂購便當，買賣關係存在於丙與何人之間？

因為案例中乙並無表示代理甲之意思，因此買賣之法律關係仍是存在於乙、丙之間，甲或丙並無直接向對方請求履約之權利，此即為間接代理之事例，雖然在乙和丙均圓滿履約的情況下，與直接代理並無太大差別，但在其中一方陷於無資力並且違約的情況下，就可能會出現差別。

四、代理與代表

至於代表[7]跟代理之間的差異，前者，係指在法人組織法上不可欠缺，代表與法人係一個權利主體間之關係，**代表人所為之行為即為法人之行為**[8]；後者，則是**使法律行為效力歸屬本人**。兩者概念上並不全然相同，然而，兩者實際上極為相似，因此實務上認為，**代表即可類推代理之相關規定**[9]。然而實務並非所有代理之規定均可類推，**如表見代理（民法第 169 條），實務認為不可類推於代表**[10]，然而，學說上有認為，縱然認為不可類推適用（狹義）表見代理，仍可透過適用民法第 107 條緩解相對人地位不對等的情況[11]。

參、有權代理

有權代理，必須代理人有代理權限，並須以本人名義為之，從事法律行為[12]。上述定義可以化約為三個要件：

一、有代理權限

代理權，係**使以代理人名義所為法律行為的效力，得直接歸屬於本人之法律上權能**，其並非權利或能力，而是**資格或是地位**[13]，在意定代理下之代理權授與，依民法第 167 條為之。

力移轉於委任人之義務而已，學說上稱之為間接代理。」最高法院 70 年度台上字第 1614 號民事判決參照。

[7] 通常爭議都會出現在公司喔！

[8] 最高法院 86 年台上字第 1782 號民事判決

[9] 「**代表與代理固不相同，惟關於公司機關之代表行為，解釋上應類推適用關於代理之規定**，故無代表權人代表公司所為之法律行為，若經公司承認，即對於公司發生效力。」最高法院 74 年度台上字第 2014 號民事判決參照。

[10] 「**民法第一百六十九條關於表見代理之規定，惟意定代理始有適用，若代表或法定代理則無適用該規定餘地**。」最高法院 79 年度台上字第 2012 號民事參照。

[11] 曾宛如，註 3，頁 734；陳自強，債之涉他關係—民法講義 V，1 版，頁 64，2022 年。

[12] 陳聰富，註 1，頁 419。

[13] 王澤鑑，註 4，頁 573。

民法第 167 條
代理權係以法律行為授與者，其授與應向代理人或向代理人對之為代理行為之第三人，以意思表示為之。

代理權之授與，性質上為有相對人之單獨行為，且非要式行為，例外為民法第 531 條：「為委任事務之處理，須為法律行為，而該法律行為，依法應以文字為之者，其處理權之授與，亦應以文字為之。**其授與代理權者，代理權之授與亦同**。」

案例：甲委任乙替甲與丙締結 A 屋之買賣契約，其代理權之授與應如何為之？

我國雖然有民法第 166 條之 1 第 1 項：「契約以負擔不動產物權之移轉、設定或變更之義務為標的者，應由公證人作成公證書。」然而，本條尚未施行，因此，**我國不動產買賣契約仍非要式行為**，因此其代理權之授與當然也無須以上開方式為之。

案例：甲委任乙替甲與丙締結 A 屋之買賣契約，並辦理該 A 屋之所有權移轉登記，其代理權之授與應如何為之？

我國不動產物權行為應該以書面為之，民法第 758 條第 2 項定有明文。是以，**不動產物權行為之代理權授與，仍應以書面為之**。

是否有代理權限，應該視本人授與之代理權之範圍，可能樣態有自始代理人無代理權或是逾越代理權限（越權代理）。

而我國尚有承認所謂的複代理，所謂複代理，為代理人授與本人之代理權給複代理人，而複代理人仍以本人之名義為法律行為，效力直接歸屬於本人[14]。至代理人與本人間之代理關係，並不因有複代理而消滅[15]。亦屬於代理權授予的形式之一。

二、以本人名義為之（表明代理意旨）

民法第 103 條第 1 項
代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力。

代理行為於代理權限內所為之意思表示，**須以本人名義為之**，學說上稱為**顯名原則**[16]，換言之，本人縱曾授與代理權於代理人，但代理人未以本人名義為意思表示時，該意思表示仍無從直接對本人發生效力[17]。

[14] 陳自強，註 11，頁 36。
[15] 法務部（80）法律字第 8022 號。
[16] 王澤鑑，註 4，頁 572。
[17] 最高法院 75 年度台上字第 1922 號民事判決。

而何謂以本人名義為之，涉及隱名代理之問題，實務上涉及隱名代理之案例，**多為本人並未被記載為契約之當事人**[18]，是以，應以契約書是否記載本人為當事人來判斷是否為隱名代理[19]。

而隱名代理，實務進一步闡釋，隱名代理之成立，**須代理人為法律行為時，雖未以本人名義或明示以本人名義為之，惟實際上有代理本人之意思，且此項意思為相對人所明知或可得而知者，始足當之**[20]，通說似乎亦贊同之[21]，而如此解釋之結果，則導致隱名代理無法在民法第 103 條文義的射程範圍下。

然而陳自強老師認為，**顯名原則的目的在於，讓第三人知悉應該向本人或代理人主張權利**。是以，**關鍵並非是否表示本人姓名，而在於表明代理意旨**，民法第 103 條之「以本人名義為之」不應狹隘的認為須以本人之姓名為之，**重點毋寧在於第三人是否明知或可得而知代理行為之效果歸屬於本人之意思，故實務之隱名代理仍為我國民法第 103 條所規範**。而既然姓名公開與否並不重要，重點在於代理意旨的表明，**那麼「代理公開原則」乃是比「顯名原則」更好的用語**[22]。

講了這麼多，既然實務和陳自強老師結論上都是會產生代理的效果，也就是本人才是契約之當事人，那討論上究竟有何實益？重點在於，實務見解下可能要額外的承認隱名代理乃是我國法無明文的代理樣態[23]，而陳自強老師認為，隱名代理也在我國民法第 103 條之範圍內[24]。因此本文認為在考試上似乎僅有引用條文上的差異。

延伸討論：本人不明之代理[25]

---

[18] 簡單來說，就是名字有沒有出現在契約書上。

[19] 陳自強，代理公開原則之再展開，月旦法學雜誌，279 期，頁 99，2018 年。陳老師的原話比較精確，原文是：「我國代理的一般理解上，受任人若以自己名義與第三人訂立契約，充其量構成間接代理，契約效力並不及於委任人。在該案，林○祥以自己名義訂立契約，最高法院認為若實際上有代理之意思，且為相對人所明知或可得而知，構成隱名代理，對被上訴人（即委任人）發生效力，從而，**最高法院所謂以「自己名義」訂立委售房地契約契約，單純指系爭契約書所記 載之當事人為受任人，所謂未以本人之名義，指契約書未記載本人為契約當事人。簡言之，隱名乃契約書未記載本人為當事人，反之，則為顯名**。」

[20] 最高法院 103 年度台上字第 781 號民事判決，該判決在 lawsnote 上顯示被引用 101 次（截止於 2024/8/15），可以認為是實務的穩定見解。

[21] 王澤鑑，註 4，頁 572。

[22] 陳自強，註 11，頁 28。但說實在的，考試上如果不要給自己那麼大的負擔，採取實務見解即可。

[23] 例如陳自強老師在書中提到胡長清老師即如此區分，參陳自強，註 11，頁 28。

[24] 陳自強，註 19，頁 117。

[25] 我覺得這個爭點有點小難，可以不用知道也沒關係？因為多數的參考書幾乎都沒有收，但是聰富老師的教科書有介紹到，我還是放進來了。

從上述的討論可以知道，在代理人不表明本人名義是可以的，那麼我們思考的兩個更進階的案例：1.**代理人不告知相對人本人姓名** 2.**本人在代理人為代理行為時未確定**。

在案例 1.狀況，**本質上為隱名代理，只是在履約時代理人不欲告知相對人本人姓名而已**。在案例 2.是根本連本人是誰都還不確定，是否應承認此種類型的代理[26]，採取肯定說者認為，**基於契約自由原則，若第三人不欲不知本人為何，大可直接拒絕**，且**依傳統法律行為要件理論，並未要求當事人於契約成立時須確定**，惟除非當事人有特約立即生效，否則契約仍需等到本人確定時方生效[27]。

那麼問題來了，**如果說這個代理人不願意告知相對人本人是誰的時候，此時相對人應該如何尋求救濟呢**？

陳聰富老師認為，**代理人通常將獲得之物移轉給本人，而本人支付對價補償，因此應由代理人承擔拒絕承認本人身分之危險**，參考德國法、DCFR 應讓代理人為無權代理人處理，**相對人得向甲請求履行契約義務或是債務不履行損害賠償**[28]。陳自強老師認為，我國並未有如同德國法之規定，若契約無約定，**毋寧透過類推適用我國民法第 575 條第 2 項[29]，其利益狀態類似，為我國法下較為可行的方案**[30][31]。

三、從事法律行為

原則上**法律行為均能被代理**，但**身分行為為了尊重本人意思，原則上不得代理**[32]，唯一的例外是未滿七歲之人之收養，可以由法定代理人代理之[33]。而**事實行為及侵權行為，非屬於法律行為，與私法自治無**

[26] 商業上是存在此種交易型態的，例如代理人為了搶奪先機，先與第三人簽訂契約，再尋覓契約當事人，大型聯貸下，聯合授信銀行團成員尚未確定之前，主辦銀行先以其他聯合授信銀行之代理人身分，簽訂借款契約，詳參陳自強，本人姓名未公開之代理，月旦法學雜誌，282 期，頁 62，2018 年。

[27] 陳自強，註 26，頁 64–66。

[28] 陳聰富，註 1，頁 423、424。

[29] 民法第 575 條第 2 項：「**居間人不以當事人一方之姓名或商號告知相對人時**，應就該方當事人由契約所生之義務，**自己負履行之責，並得為其受領給付**。」

[30] 陳自強，註 26，頁 74、75。

[31] 或許有認為可以透過民法第 110 條無權代理損害賠償即可解決，然而，我國民法第 110 條損害賠償之範圍是否為履行利益是有爭議的，且損害賠償責任和履行契約責任仍然有所差異，故保護上仍有不周之處。

[32] 王澤鑑，註 4，頁 571。

[33] 民法第 1076 條之 2 第 2 項：「被收養者未滿七歲時，應由其法定代理人代為並代受意思表示。」

關，不適用代理規定[34]，至於**準法律行為**（例如債務承認[35]）則可**類推適用法律行為之規定，故亦可代理**[36]。

四、代理權之行使

(一) 共同代理權

> 民法第 168 條
> 代理人有數人者，其代理行為應共同為之。但法律另有規定或本人另有意思表示者，不在此限。

又代理人有數人，除法律另有規定或本人另有意思表示者外，其代理行為應共同為之（民法第 168 條規定參照），否則為無權代理行為[37]。

(二) 雙方代理禁止

> 民法第 106 條
> 代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。但其法律行為，係專履行債務者，不在此限。

本條規範自己代理與雙方代理，其用意在於**保護本人**在利益衝突下的利益，而本條設有例外：**本人同意或專履行債務者**，前者，因為**本條係保護本人利益，當然可以處分**；後者，**履行債務對本人並無不利益，故無禁止之必要**[38]。而民法第 106 條自己代理之禁止規定，於法定代理亦有其適用[39]。

1. 自己代理

自己代理，係**代理人一方面以本人名義為法律行為，一方面又以自己名義為法律行為**[40]。如：

> 案例：本人甲委任乙幫忙處理公司事務，並授與代理權，乙向甲提出加薪要求，又以甲之名義承諾之。

而自己代理的效力為何？實務、學說均認為，本條雖為強行法，但**目的在於避免利益衝突而和公益無關**，且因本條為代

34 陳聰富，註 1，頁 420。
35 債務承認性質上實務認為是觀念通知，為準法律行為，參最高法院 88 年台上字 1299 號民事判決。
36 陳聰富，註 1，頁 419。
37 最高法院 110 年度台上字第 2582 號民事判決
38 陳聰富，註 1，頁 433。。注意清償並不包含代物清償，因其仍有利益衝突的可能。
39 最高法院 79 年度台上字第 2181 號判決意旨參照
40 陳自強，債之涉他關係一版，2022 年，頁 44、45。

理權之限制，**故僅為無權代理，並非無效**[41]。

另外，因為本條乃是為了保護本人利益，因此在**代理人贈與給本人的情況下，可以目的性限縮解釋本條**，而為有權代理[42]。

2. 雙方代理

雙方代理，指代理人代理本人又代理第三人[43]，如：

> 案例：乙為甲、丙之代理人，乙代理甲提出出賣 A 車之意思表示，乙代理丙為承諾之意思表示

雙方代理之效力，學說、實務均認為本條雖為強行法，但目的在於**避免利益衝突，而和公益無關**，且因本條為代理權之限制，故**僅為無權代理，並非無效**[44]。

五、代理權之消滅

> 民法第 109 條
> 代理權消滅或撤回時，代理人須將授權書交還於授權者，不得留置。

代理權消滅或撤回後，代理人自無從為有權代理，而本人若有交付授權書者，代理人亦須交還。然而，何時構成代理權消滅或撤回，分述如下：

(一) 基礎法律關係消滅？

代理權之授與，時常伴隨著一定的基礎法律關係，例如委任契約，而**代理權是否會因為基礎法律關係消滅而一併消滅**，涉及**授權行為無因性**之問題

> 民法第 108 條
> I. 代理權之消滅，依其所由授與之法律關係定之。
> II. 代理權，得於其所由授與之法律關係存續中撤回之。但依該

41 實務見解如：「是被上訴人逕以其法定代理人馬樹禮聲請辦理移轉系爭土地所有權，有自己代理或雙方代理之事。而行為時之土地登記規則第二十五條規定，原則上雖應由登記申請人親自會同辦理，如不能親自申請辦理時，得由代理人為之，而其效力仍直接歸屬登記申請人。因此，縱被上訴人於辦理系爭土地移轉所有權登記時有自己代理或雙方代理之情形，然其無權代理行為之效力，亦因嗣後中華民國行政院、財政部於前述政府機關函文核定同意追認，故其移轉系爭土地之物權行為效力仍屬有效，並未違反行為時土地登記規則第二十五條之規定。」最高法院 101 年度台上字第 1599 號民事判決參照。學說見解參陳聰富，註 1，頁 432；陳自強，民法總則法律行為—民法講義 I，5 版，頁 45，2023 年。

42 陳聰富，註 1，頁 433、434。實務見解可參最高法院 59 年度台上字第 4401 號民事判決。

43 陳聰富，註 1，頁 432。

44 實務見解：「禁止雙方代理旨在保護本人之利益，依民法第一百零六條前段規定，代理人經本人許諾，得為雙方代理之法律行為。禁止雙方代理之規定，既非為保護公益所設，自非強行規定，如有違反，其法律行為並非無效，經本人事後承認，仍生效力。」最高法院 85 年度台上字第 106 號民事判決參照。學說見解參陳聰富，註 1，頁 432；陳自強，註 11，頁 45。

法律關係之性質不得撤回者，不在此限。

自文義上來看，立法者似乎採取授權行為有因性之解釋，然而解釋上仍有爭執。

案例[45]：乙 17 歲而受雇於甲之便利商店擔任店員，以甲名義出售商品，而乙之法定代理人丁認為乙應該專心讀書，故不同意。試問：

1. 甲乙之間有哪些法律行為？效力如何？
2. 乙與顧客丙之買賣契約是否對甲發生效力

王澤鑑老師採取無因性之見解，認為 1.肯定無因性並不違反授權人之意思，對代理人亦無不利 2.若**採取有因性之解釋，則未成年人可能會負擔民法第 110 條之責任** 3.肯定無因性可以**保護交易安全**[46]4.民法第 108 條第 1 項文義之射程範圍僅止於基礎關係消滅，並不及於無效或不成立[47]。

實務有採取授權行為有因性之見解者，認為在基礎關係消滅後，代理權亦隨同消滅[48]。陳自強老師亦採取有因性之見解，認為 1.物權行為與代理權授與行為均必然有法律上原因，若無法律上原因時，物權行為採取無因性而造成的不利益，可以透過不當得利加以矯治，**代理權行為則透過民法第 108 條使得授權行為與基礎關係相連結，而處於類似於不當得利之功能** 2.代理權乃是為了本人利益而存在，**若基礎關係不生效力，理性的本人也不會希望代理人繼續享有代理權限** 3.**交易安全的問題，實際上可以透過民法第 107 條來處理**[49]4.**為了保護未成年人**，學說上有認為**未成年人無**

[45] 案例節錄自王澤鑑，註 4，頁 587；陳自強，註 11，頁 49。

[46] 詳言之，基礎關係並非第三人所能夠輕易得知者，**若採取有因性之見解，則相對人必然需要去查證基礎關係是否有效來避免無權代理的情況**，然而相對人多不會進行查證，而導致無權代理的結果。

[47] 王澤鑑，註 4，頁 587、588。

[48] 「況按代理權之消滅，依其所由授與之法律關係定之。民法第一百零八條第一項定有明文。在意定代理，其代理權應因其所由授與之法律關係終了而消滅。查依授權書所載，鄭吉田授權上訴人全權處分系爭土地之基本法律關係為委任契約，又被繼承人生前委任之代理人，依民法第五百五十條規定，其委任關係，除契約另有訂定，或因委任事務之性質不能消滅者外，自應歸於消滅。所謂契約另有訂定，係指委任契約訂定無論何方死亡委任關係仍繼續存在之特約而言。查本件授權書並無委任人死亡，委任關係仍繼續存在之特別約定，至該授權書上所載之授權期間：「自中華民國八十二年十二月七日起至無限期止」，其涵義係指此項委任及授權並無時間限制之意，參照上訴人自承：「鄭吉田不意（料）書立授權書後數月即死亡，致無法順利辦理移轉登記」等語，更足認上訴人與鄭吉田訂立授權書時，並未就鄭吉田於書立授權書後死亡之可能性予以考量，故此項授權期間為「無限期」之記載，不能認係鄭吉田與上訴人間已就「鄭吉田死亡後，委任關係仍然繼續存在」之特約，則上訴人與鄭吉田間之委任關係，因鄭吉田死亡而消滅，委任關係既已消滅，上訴人代理鄭吉田處分系爭土地之代理權亦隨同消滅。」最高法院 89 年度台上字第 222 號民事判決參照。

[49] 不過要注意的是，這裡是否可以適用民法第 107 條有爭議，若認為不得適用的話交易安全仍無法被保障。

須負擔民法第 110 條無權代理之損害賠償責任者[50]，故有因性之見解未必造成未成年人保護不周[51]。

(二) 撤回代理權

民法第 108 條

I. 代理權之消滅，依其所由授與之法律關係定之。

II. 代理權，得於其所由授與之法律關係存續中撤回之。但依該法律關係之性質不得撤回者，不在此限。

即便採授權行為有因性之見解，仍無礙於代理權限乃是獨立於基礎法律關係之地位，是以，即便基礎關係仍然存在，本人仍可撤回代理權，此時受任人仍可透過間接代理的方式來處理委任事務。

(三) 本人死亡或代理人死亡

代理權並非權利，無法為讓與，同時也無法獨立繼承，是以，本人或代理人死亡時，取決於基礎關係，若基礎關係因為死亡消滅而無法繼承，則代理權亦歸於消滅[52]。

而代理權授予的基礎關係，通常是委任契約，委任契約是否於本人或代理人死亡時歸於消滅而無法繼承，取決於民法第 550 條。

民法第 550 條

委任關係，因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但契約另有訂定，或因委任事務之性質不能消滅者，不在此限。

(四) 代理人喪失行為能力

代理人喪失行為能力時，因為無法為有效之法律行為，故其代理權消滅；而本人喪失行為能力時，因為先前做成之授權行為仍有效，故代理人之代理權不受影響[53]。

肆、（狹義）無權代理

民法第 170 條

[50] 陳聰富，註 1，頁 446。
[51] 陳自強，註 11，頁 49–51。
[52] 陳自強，註 11，頁 52；實務見解：「民法第五百五十條但書雖規定契約另有訂定者，委任關係不因當事人之死亡而消滅，惟此時當事人既已死亡，自係由繼承人承繼當事人在委任關係中之地位。又依民法第一百零三條第一項規定代理人應以本人之名義為意思表示，故於受有代理權之委任，受任人於本人死亡後，應以其繼承人之名義為法律行為。」最高法院 87 年度台上字第 2341 號民事判決參照。學說上亦有相同結論，然並未承認代理權是否消滅繫諸於基礎關係者，參王澤鑑，註 4，頁 592。
[53] 陳聰富，註 1，頁 440；王澤鑑，註 4，頁 592。

I. **無代理權人以代理人之名義**所為之**法律行為，非經本人承認，對於本人不生效力**。

II. 前項情形，法律行為之相對人，得定相當期限，催告本人確答是否承認，如本人逾期未為確答者，視為拒絕承認。

這邊按照條文文義的話，所謂的無權代理，似乎是無代理權人以代理人之名義所為之法律行為，然而有權代理的定義則是代理人有代理權限，並須以本人名義為之，從事法律行為，似乎兩者的差別有二：1.代理權限的有無 2.以代理人或是以本人名義為之，然而學說上有不同闡釋：

延伸討論：無權代理應以代理人名義為之？

無權代理之定義為何？學說上與條文文義做出相同解釋而認為無權代理，指無代理權人**以代理人名義**而為法律行為[54]，而實務上亦有採取相同見解的裁判[55]；亦有學說對無權代理做出不同的定義，認為無權代理，指無代理權之人，**以本人名義**，為法律行為[56]。

那麼兩說的差別在於：無權代理究竟係以本人名義或是以代理人名義為之呢？按照我們前面所說，以誰的名義為之的重點在於：在代理人和相對人之間的法律關係，雙方究竟希望效力發生在誰身上？如果按照這個前提的話，即便是無權代理，代理人和相對人也絕非希望發生在代理人身上（否則就不是代理而是間接代理啦），所以本文認為「**無權代理指無代理權之人，以本人名義，為法律行為**」的定義較為正確，但即便採取以代理人名義的學說，實際上的操作也和另外一說並無不同，所以我想這應該只是法條用語上的誤用而已！

所以講了這麼多，無權代理的定義即是：無代理權之人，以本人名義，為法律行為。後續的部分也是以這個為前提進行討論，請注意喔！

一、代理人欠缺代理權

無代理權可能有幾種情況：1.自始未授與代理權 2.授權行為無效或被撤銷 3.逾越代理範圍 4.代理權消滅[57]。

---

54 陳自強，註 11，頁 58。

55 「無代理權人**以代理人之名義**所為之法律行為，係效力未定之法律行為，固得經本人承認而對於本人發生效力。惟本人如已為拒絕承認，該無權代理行為即確定的對於本人不生效力，縱本人事後再為承認，亦不能使該無權代理行為對於本人發生效力。」最高法院 85 年度台上字第 963 號民事判決參照。然而實務上比較明確採取此說的判決大概是這個，Lawsnote 的引用次數為 197 次，可以說是相當有影響力的判決，下級審亦有採取相同見解者，例如：「所謂無權代理，則係指無代理權人**以代理人之名義**而為法律行為，民法第 103 條第 1 項、第 110 條分別定有明文。」臺灣臺北地方法院 106 年度訴字第 4107 號民事判決參照，臺灣高等法院 104 年度重上字第 608 號民事判決、臺灣高等法院 102 年度重上更(二)字第 81 號民事判決同旨。

56 陳聰富，註 1，頁 441；王澤鑑，註 4，頁 600。

57 陳聰富，註 1，頁 441、442。

二、以本人名義為之（如前所述）

三、為法律行為（如前所述）

四、效果

(一) 代理行為效力未定

無代理權人以代理人之名義所為之法律行為，係效力未定之法律行為，固得**經本人承認而對於本人發生效力**。**惟本人如已為拒絕承認，該無權代理行為即確定的對於本人不生效力**，縱本人事後再為承認，亦不能使該無權代理行為對於本人發生效力[58]。

而為了保護相對人，按民法第 170 條第 2 項規定相對人得定相當期限，催告本人確答是否承認，如本人逾期未為確答者，視為拒絕承認，亦可依照民法第 171 條在本人同意之前撤回意思表示使意思表示不生效力。

(二) 無權代理人損害賠償責任

民法第 110 條

無代理權人，以他人之代理人名義所為之法律行為，對於善意之相對人，負損害賠償之責。

本條係規定無權代理人的損害賠償責任，性質上屬於**法定擔保責任**，是以，**不以無代理權人可歸責為必要**[59]，應該注意的是，相對人並**不能以本條要求代理人履行契約**[60]，因為契約自始至終都沒有生效。

另外，於代理人是未成年人的情況下，通說認為，基於未成年人的保護應優先於交易安全，應對民法第 110 條進行目的性限縮解釋，認為於**代理人是未成年人的情況下不適用本條**[61]。

---

[58] 最高法院 85 年度台上字第 963 號民事判決

[59] 陳自強，註 26，頁 76、77；應該注意的是，陳聰富老師更進一步說明，本條係締約上過失的一種型態，然而締約上過失並不以過失為必要，毋寧是以信賴關係為基礎，參陳聰富，締約上過失的責任構成與救濟方法，政大法學評論，169 卷 169 期，頁 233、234，2022 年。

[60] 「被上訴人公司非以保證為業務，其負責人違反公司法第二十三條之規定，以公司名義為保證，依司法院釋字第五十九號解釋，其保證行為應屬無效，則上訴人除因該負責人無權代理所為之法律行為而受損害時，得依民法第一百十條之規定請求賠償外，並無仍依原契約，主張應由被上訴人負其保證責任之餘地。」最高法院 48 年度台上字第 1919 號民事判決參照。

[61] 王澤鑑，註 4，頁 605；陳聰富，註 1，頁 446。實務見解可參法務部法律字第 10000603030 號。

1. 損害賠償之範圍

然而本條的損害賠償的範圍究竟為何？眾說紛紜，有認為應該以**信賴利益**為損害賠償的範圍[62][63]，亦有認為以**履行利益**損害賠償的範圍[64]。

不過現在的多數見解認為，以代理人善、惡意（是否明知其無代理權）而異其損害賠償的範圍，**若惡意則為履行利益，若善意則為信賴利益**[65]。

區分說的理由在於：因為無權代理人的損害賠償基礎，在於主張自己有代理權，相對人因而信賴該外觀而為法律行為，基於完全賠償原則，應使相對人的地位如同契約訂立一樣，然而**本條既然是無過失責任，若一律使得相對人負擔履行利益的責任似有過苛，故透過善、惡意的方式進行調節**[66]。

2. 消滅時效

本條的消滅時效為何？**實務認為，既然本條並無特別規定，應該適用民法第 125 條**[67]；而**王澤鑑老師認為，依照該契約**

---

[62] 陳添輝，無權代理人對善意相對人之責任，政大法學評論，146 期，頁 244–248，2016 年；不過需要注意的是，陳添輝老師乃是認為本條是締約上過失，而認為本條的損害賠償範圍以信賴利益為限，但應注意的是，締約上過失是否以信賴利益為限，學說上仍有爭議，認為可能包含履行利益者，參陳聰富，註 59，頁 243、244。

[63] 雖然或許有認為最高法院 85 年度台上字第 2072 號民事判決：「無權代理人之責任，係基於民法第一百十條之規定而發生之特別責任，相對人依該條規定請求損害賠償，不得超過相對人因契約有效所得利益之程度。是在原契約中如就契約債務履行不能或不為履行等應給付違約金有特別約定，且該約定之違約金屬損害賠償額預定性質者，相對人向無權代理人請求之賠償額自應以該預定額數為限，不得更請求履行或不履行之損害賠償。」而認為有實務見解採取信賴利益說，然而學說上對於本則判決均認為並非採取信賴利益，而是履行利益，參陳聰富，註 1，頁 446；王澤鑑，註 4，頁 600。

[64] 「按無權代理人之責任，係基於民法第一百十條之規定而發生之特別責任，祇要相對人係屬善意，即不知自命代理人無代理權，縱使相對人因過失而不知，無權代理人仍應負其責任；又相對人依該法條規定請求損害賠償，不得超過相對人因契約有效所得利益之程度，易言之，相對人得請求履行利益之給付。」最高法院 90 年度台上字第 1923 號民事判決參照。

[65] 王澤鑑，債法原理，增訂新版校正版，頁 319、320，2024 年；陳聰富，註 1，頁 445、446。

[66] 陳自強，註 11，頁 77、78。

[67] 「無權代理人責任之法律上根據如何，見解不一，而依通說，無權代理人之責任，係直接基於民法之規定而發生之特別責任，並不以無權代理人有故意或過失為其要件，係屬於所謂原因責任、結果責任或無過失責任之一種，而非基於侵權行為之損害賠償。故無權代理人縱使證明其無故意或過失，亦無從免責，是項請求權之消滅時效，在民法既無特別規定，則以民法第一百二十五條第一項所定十五年期間內應得行使，要無民法第一百九十七條第一項短期時效之適用，上訴人既未能證明被上訴人知悉其無代理權，則雖被上訴人因過失而不知上訴人無代理權，上訴人仍應負其責任。」最高法院 56 年度台上字第 305 號民事判決參照，最高法院 90 年度台上字第 829 號民事判決同旨。

履行請求權而定[68]；**陳自強老師**認為，若**無權代理人為惡意，則依照該契約履行請求權而定**；若**無權代理人為善意，負擔者為信賴利益，應該類推適用民法第 245 條之 1 第 2 項兩年時效**[69]。

縛約上過失

伍、（廣義）表見代理[70]

（廣義）表見代理	越權代理	要件	限制代理權
			撤回代理權
		效果	不得對抗善意第三人
	（狹義）表見代理	表示授權	由自己之行為表示以代理權授與他人
		容忍授權	知他人表示為其代理人而不為反對之表示者

首先，應該釐清，**不管是民法第 107 條或是第 169 條，其成立的前提都是無權代理，若為有權代理，則直接依照民法第 103 條對本人發生效力即可**，因此在進入上述兩條的檢討之前，都需要先確定個案上成立無權代理。

而（廣義）表見代理，其制度目的在於，讓無權代理的情況下，交易之效力仍然可以對本人發生效力，其正當化之基礎在於：**權利外觀理論，權利外觀理論，乃是因為交易上有讓相對人信賴代理人有代理權之外觀，而該信賴之外觀可歸責於本人，且該相對人之信賴具有正當性（值得保護）**[71]，此理論基礎在學習此部分時，應該謹記於心，即可事半功倍。

一、民法第 169 條：（狹義）表見代理（或稱表見授權）

> 民法第 169 條
> **由自己之行為表示以代理權授與他人**，或**知他人表示為其代理人而不為反對之表示**者，對於**第三人應負授權人之責任**。但**第三人明知其無代理權或可得而知者，不在此限**。

（狹義）表見代理可以區分為兩種情況：

(一) 表示授權

---

[68] 王澤鑑，註 4，頁 605、606。例如租金就適用民法第 126 條之租金時效。
[69] 陳自強，註 11，頁 78。
[70] 關於民法第 107 條是否屬於（廣義）表見代理，學說上雖有爭論，但實際上只要廣義表見代理的法理可以一併援用的話，此問題實益並不大，參陳自強，註 11，頁 60。
[71] 陳自強，註 11，頁 60–62。

即條文所稱由自己之行為表示以代理權授與他人，例如：

> 案例：甲經營雜貨店，並聘請乙作為員工，並授與代理權負責訂貨事宜，同時交付印鑑章與空白支票，乙為了清償在外的欠款，因此持蓋有甲姓名的支票向丙清償。

然而應注意的是，條文規定由自己之行為表示「以代理權授與」他人，在**表示授權的情況下是否要求先有授權行為**？實務有判決採取肯定說[72]；學說則多採取否定說，理由在於，表見代理本質上係無權代理，若有授權行為則無從成立表見代理之可能，且**從權利外觀理論來說，重點在於有無代理權存在之外觀，實際上有無授權行為並不重要**[73]，是以，本條應解為自己之行為表示創造代理權之外觀。

然而，自己之行為表示創造代理權之外觀之該行為，**是否以積極行為為限**？例如：

> 案例：甲之印鑑章、空白支票遭小偷乙拿走，乙藉此開立一張甲之名義的支票。

此時對甲是否有民法第 169 條前段的適用，**有採肯定說者，認為權利外觀是否存在，應由相對人角度判斷，其外觀是否由本人積極行為導致，並不重要**[74]；亦有採取**否定說者認為，權利外觀對本人來說並無客觀的可歸責性，故無表見代理的適用**[75]。

就此問題，本文認為否定說較為可採，從風險分配的角度來說，本人積極行為導致權利外觀的情況下，通常本人避免該權利外觀存在的成本比相對人更低[76]，所以風險應該由本人承擔，然而在本人並無積極行為創造權利外觀的情況下，本人亦難以避免該權利外觀的存在，是以，較無證成本人須負責的正當化基礎。

而實務上究竟要如何才會被認定為有權利外觀存在？實務似乎尚

---

[72] 「民法第一百六十九條關於由自己之行為表示以代理權授與他人者，對第三人應負授權人之責任之規定，原以本人有使第三人信為以代理權授與他人之行為，為保護代理交易之安全，有使本人負相當責任之必要而設，使本人就他人以其名義與第三人所為之代理行為，負與授權人同一之責任。該項規定，須以他人所為之代理行為，係在其曾經表示授與他人代理權之範圍內為其前提要件。」最高法院 77 年度台上字第 730 號民事判決參照，最高法院 40 年度台上字第 1281 號民事判決、最高法院 90 年度台上字第 1187 號民事判決同旨。

[73] 陳自強，註 11，頁 67；陳聰富，註 1，頁 450、451。

[74] 陳聰富，註 1，頁 451。

[75] 王澤鑑，註 4，頁 600；陳自強，註 11，頁 61、67。

[76] 例如如果你的員工離職了，就應該要叫他把印章之類的東西還回來，但如果是相對人要查證的話，可能還要打到公司問阿，然後公司還要確定這個交易到底是離職前還是離職後做的巴拉巴拉一大堆。

無穩定的看法[77]，從考試的角度來說，僅需充分涵攝，分數上應無不利益。

(二) 容忍授權

即條文的知他人表示為其代理人而不為反對之表示者，容忍授權的要件有二：**1.知他人表示為其代理人 2.不違反對之表示者**，前述的權利外觀理論，必須要本人可歸責的創造了權利外觀，而**本人名之代理人之無權代理行為卻不為反對，使相對人相信該代理人有代理權[78]，而創造了權利外觀**。

然而應該澄清的是：**如果無權代理後本人知悉而不為反對之表示，該無權代理是否可以援引本條而生效？**例如：

> 案例：乙無權代理甲向丙購買 A 車，丙後來知悉乙並無代理權後，通知甲是否願意承認，甲未置可否。

實務認為，此時無從援引本條作為生效之基礎。本文認為，實務見解值得贊同，因為本案例之情況，應該要是民法第 170 條所規定之拒絕承認。所以本條要處理的情況應該是：

> 案例：乙數次無權代理甲向廠商丙購買甲工廠所需之原料，然而甲明知乙代理自己訂貨，卻均未置可否。

因此學說上認為，**容忍授權需有一定期間與重複性，本人始具可歸責性而應負責，一次性的無權代理較難成立有正當信賴之權利外觀**[79]。

(三) 第三人非明知或可得而知

若相對人明知或可得而知代理人無代理權，其信賴並不值得保護，因此無法賦予其表見代理之效果而使本人負責。

(四) 效果：本人應對第三人負授權人責任

此時代理之法律行為依照本條對本人發生效力，相對人可以據此向本人請求履行契約責任。

然而較有爭議者：**相對人可否不援引本條向本人主張權利，而依民法第 110 條主張損害賠償？**有區分論者認為，本人既然因為本

---

[77] 實務見解超級多的啦，就不編進來了，有興趣的話可以去看老師的教科書，裡面有蠻多判決的！

[78] 一般人被無權代理的時候應該都會馬上反對阿！想說怎麼有怪怪的人在用我的名義亂買東西呢

[79] 陳聰富，註 1，頁 453。

條而須承擔授權人責任而使法律行為效力發生在本人，交易目的已經達成了，**無須賦予相對人主張損害賠償的必要，例外在本人不知所蹤時方賦予相對人損害賠償之權利**[80]；有肯定說認為，表見代理本質上仍是無權代理，當然可以適用民法第 110 條，而**由相對人擇一行使，避免代理人被迫與不願訂約之本人成立契約關係**[81]。

二、民法第 107 條：越權代理

> 民法第 107 條
> 代理權之**限制及撤回**，不得以之對抗善意第三人。但第三人因過失而不知其事實者，不在此限。

本條之目的在於，代理並無公示方式，第三人難以得知其代理權之範圍。是以，即便在代理權授予後，仍有保護交易安全之需求。

(一) 代理權之限制及撤回

而本條規定代理權之限制及撤回，**意味著本條所適用之狀況，必須要是本人有授與代理權之行為**[82]，而撤回，係指依民法第 108 條第 2 項撤回之。較有爭議者，**限制是否限於嗣後限制？**例如：

> 案例：甲授與代理權給乙，委任乙將甲所有之 A 屋出租，並限制僅有在月租兩萬以上方有代理權限，然而授權書未記載此限制，乙將 A 屋以一萬出租給丙。

有學說認為，**基於本條立法理由[83]而認為本條應該限於授權行為後之限制（嗣後限制）**[84]；亦有學說、實務[85]認為，**自始限制仍有**

---

80 王澤鑑，債法原理，增訂新版校正版，頁 328、329，2024 年；不過應該注意的是，王澤鑑老師討論本問題的時候乃是在民法第 107 條下討論，然而陳聰富老師卻仍引用在民法第 169 條的討論下，本文認為，應該是兩條本質上均為無權代理，故均會面臨到此問題，可援引相同討論，參陳聰富，註 1，頁 461。

81 陳聰富，註 1，頁 456。

82 「民法上所謂代理，係指本人以代理權授與他人，由他人代理本人為法律行為，該代理人之意思表示對本人發生效力而言。**故必先有代理權之授與，而後始有民法第一百零七條前段「代理權之限制及撤回，不得以之對抗善意第三人」規定之適用**。」最高法院 62 年度台上字第 1099 號民事判決參照。

83 本條立法理由為：「**謹按本人將代理權授與代理人之後，非必不可加以限制也**。又既經授與代理權之後，亦非不可仍將代理權撤回也。惟其限制及撤回，均不得對抗善意之第三人。蓋代理權之受有限制及被撤回與否，第三人固無由知之，若許其得以對抗，是使善意第三人常蒙不測之損害也。故除其限制及撤回之事實，本可得知，而由於第三人自己之過失陷於不知者外，均不得以其代理權之限制及撤回為對抗之理由。蓋為保護善意第三人之利益計也。」

84 王澤鑑，註 65，頁 327、328；王澤鑑，註 4，頁 607、608。

85 「原審以：按代理權之限制及撤回，不得以之對抗善意第三人。但第三人因過失而不知其事實者，不在此限。民法第一百零七條定有明文。上訴人與被上訴人之代理人林敏卿訂立系爭房地買賣契約，總價金為六百三十萬元；**而林敏卿係被上訴人委請代理銷售系爭房地之人員，平時並持有被上訴人印章；同工地之其他房屋，亦均由林敏卿代被上訴人銷售，林敏卿有代理被上訴人銷售系爭房地並簽約之權限**。則被上訴人於授權林敏卿銷售系爭房地之同時，**縱有銷售**

權利外觀，故可適用民法第 107 條[86]。

而在代理權消滅後是否可以適用本條，例如：

案例：甲授予代理權給員工乙代理甲向丙訂貨，並給予授權書，然而乙離職之後，並未繳回授權書，乙卻仍代理甲向丙訂貨。

民法第 109 條規定，代理權消滅或撤回時，代理人須將授權書交還於授權者，不得留置。在代理權撤回時，當然可以適用民法第 107 條並無疑義，然而在本案例中，如果採取有因性之見解，代理權消滅，但代理人並未繳回授權書，此時是否有本條適用？學說認為，此時仍有信賴外觀，縱無法適用，亦應類推適用[87]。

(二) 善意第三人

本條善意是否包含可得而知代理人無代理權？從本條但書排除過失不知無代理權來看，善意應該不包含可得而知代理人無代理權，**然而結論上只要是明知或可得而知他人無代理權（代理權之限制及撤回），即無本條之適用**。從權利外觀理論來看，此要件之限制即是在判斷相對人之信賴是否值得保護。

(三) 效果：不得對抗第三人

所謂不得對抗第三人，即是本人不得以代理權之限制及撤回向相對人主張無權代理。是以，**相對人可向本人主張負擔該法律行為之責任**。

而相對人能否不主張本條而主張民法第 107 條，討論的脈絡大致上和民法第 169 條相同，不予贅述。

價格之限制，揆諸前揭規定，既非上訴人所得知悉，被上訴人亦不得以此對抗善意之上訴人，林敏卿本於代理人之地位，以被上訴人名義與上訴人簽訂買賣價金六百三十萬元之買賣契約，自直接對被上訴人發生效力。」最高法院 89 年度台上字第 1326 號民事判決參照。注意的是最高法院在這個部分完全援引第二審的見解卻未予廢棄而可推知最高法院應該肯定包含自始限制，相同解讀亦可參王澤鑑，註 4，頁 607、608。

[86] 陳自強，註 11，頁 66。

[87] 陳自強，註 11，頁 67。